

1501383-11.2022.8.26.0537

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Maria da Conceição Pinto Vendeiro

Comarca: Diadema

Foro: Foro de Diadema

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 14/10/2022

... M.P entendeu que deve ser aplicado o tráfico privilegiado, apesar da grande quantidade de drogas, diante da primariedade e por possuir ocupação lícita.

Observo que nos casos em que o autor do crime é considerado "mula" do tráfico, que foi contratado para transporte único, a jurisprudência do STJ e do STF é no sentido que apenas a grande quantidade de drogas, não conduz ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Diadema

Foro de Diadema

3ª Vara Criminal

Avenida Sete de Setembro, 399, . - Vila Conceição

CEP: 09912-010 - Diadema - SP

Telefone: (11) 4056-6600 - E-mail: diadema3cr@tjsp.jus.br

1501383-11.2022.8.26.0537 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1501383-11.2022.8.26.0537 Controle nº 1010/2022

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JOÃO VICTOR BORGES DE OLIVEIRA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Maria da Conceição Pinto Vendeiro

VISTOS, ETC.

JOÃO VICTOR BORGES DE OLIVEIRA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no art. 33, "caput", da Lei n.º 11.343/06, porque no dia 29 de junho de 2022, por volta das 11:00 horas, na Praça Vereador Juarez Rios de Vasconcelos e na Av. Prestes Maia, altura do numeral 1063, Bairro Jardim Campanário, adquiriu, trazia consigo e transportou, para consumo de terceiros, maconha e cocaína (com peso total aproximado de 15 kg) drogas que determinam dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

A prisão em flagrante foi convertida em prisão preventiva na audiência de custódia (fls. 41/45), tendo sido reapreciada em 22.09.22 e mantida (fls. 90).

Foi apresentada defesa prévia (fls. 85/86), sendo recebida a denúncia em 22.09.22 (fls. 89/90). Na instrução foram ouvidas as testemunhas arroladas pelas partes, ocorrendo a desistência quanto à faltante. O réu foi interrogado no final, em razão do princípio da ampla defesa e conforme entendimento do STF que o art. 400 do CPP se aplica aos ritos especiais.

A Dra. Promotora de Justiça requereu a condenação, por entender estarem provados os fatos descritos na denúncia, aplicando-se a redução do art. 33, §4.º e fixação de regime aberto.

O Defensor Público requereu a absolvição por insuficiência de provas ou em caso de eventual condenação a aplicação da redução do art. 33, § 4.º, aplicação do art. 387, § 2.º, do CPP, fixação de regime aberto e substituição por pena restritiva de direitos.

É O RELATÓRIO.

DECIDO.

Na fase policial (fls. 13/14), o acusado confessou a prática do crime. Disse que é natural do Estado do Piauí, mas estava residindo com a mãe há cinco meses no município de Osasco. Falou que trabalhava como atendente, com registro em carteira, no "Ragazzo" e ganhava R\$ 950,00 por mês. Informou ser usuário de maconha e que havia recebido uma proposta de um homem conhecido por "Moreno" para transportar drogas de Diadema até Osasco pelo pagamento de R\$ 2.000,00. Afirmou que aceitou a proposta em razão de dificuldades financeiras. Então, solicitou uma corrida pelo aplicativo Uber até este município de Diadema, desembarcou no local informado por "Moreno" e aguardou uma pessoa entregar uma mochila de viagem com as drogas.

Relatou que recebeu a mochila com as drogas, pediu ao motorista que a deixasse guarda-la no porta-malas do carro, em seguida embarcou no veículo e seguiu viagem. Narrou que momentos depois o veículo foi interceptado por uma viatura descaracterizada. Disse que foi abordado e revistado, não sendo localizado nada de ilícito consigo, e que ao vistoriarem o porta-malas do veículo os policiais encontraram a mochila com as drogas (tabletes de maconha e cocaína). Afirmou que confessou que estava transportando as drogas e que não havia recebido o pagamento pelo serviço. Informou que já havia sido preso e processado por receptação no Estado do Piauí.

Em juízo, narrou que estava passando por dificuldades, porque trabalhava no Regazzo, morava sozinho, não tinha o que comer, pois pagava aluguel. Recebeu a proposta para transportar uma mala e acabou aceitando. Recebeu a mala, pegou um Uber e foi abordado. Informou que sabia que a mala continha algo ilegal e que usa cocaína e maconha. Nada tem contra os policiais. Trabalhava registrado no Ragazzo Express como atendente e seu chefe aguarda que retorne para promovê-lo.

Os policiais, na fase extrajudicial (fls. 03/08), disseram que durante investigações obtiveram a informação de que naquela manhã, nas imediações da Praça Vereador Juarez Rios de Vasconcelos, um homem de alcunha "Bahia" (magro, pardo, estatura mediana, com cicatriz no cotovelo direito) estaria no local negociando uma grande quantidade de drogas. Relataram que no local se depararam com o réu, que possui características idênticas às descritas no informa anônimo, parado na via pública, segurando uma mochila tipo "de viagem". Narraram que em seguida um veículo VW/Fox parou, o réu guardou a mochila no porta-malas deste, embarcou no banco de trás e seguiu viagem. Falaram que acompanharam o veículo até a Av. Prestes Maia, altura do numeral 1063, no semáforo, quando efetuaram a abordagem. Narraram que o motorista, identificado como Anselmo José Santana, atendeu prontamente a ordem de parada e desembarcou. Em seguida o réu, que não portava documentos, desceu do veículo e o revistaram. Porém, ao verificarem o porta-malas do veículo, localizaram a mochila que haviam visto o réu guardar e no interior daquela encontraram diversos tabletes de maconha e cocaína. Afirmaram que o motorista declarou que trabalhava como motorista de transporte por aplicativo e estava fazendo uma corrida para o réu, que a havia solicitado via aplicativo Uber (exibiu o aplicativo ligado no celular dele), e declarou que desconhecia o conteúdo da mochila. Informaram que o réu confessou que havia sido contratado para retirar as drogas em Diadema e transportá-las até Osasco.

Fernando (policial), em juízo, narrou que receberam denúncia anônima que na Praça haveria transporte de drogas, dando as características físicas do homem. Avistaram o réu parado na Praça, o qual tinha as características informadas. Manobram a viatura e ao retornar o réu já estava com uma mala. Em seguida, apareceu um veículo, o réu colocou a mala no porta-malas e entrou no mesmo. Resolveram seguir e depois abordar o carro e na mochila que estava no porta-malas havia drogas. O

motorista estava com o aplicativo Uber ligado. O réu confessou que foi contratado para fazer o transporte de drogas, mas não sabia a quantidade, nem quais eram. Disse que recebeu a bolsa na praça de um homem, e ia levar para Osasco e que chamou um motorista de aplicativo. Praticou o crime por dificuldades financeiras, porque trabalhava no Ragazzo.

No mesmo sentido foi o depoimento judicial do policial Éder.

O fato de a testemunha ser policial não a torna impedida ou suspeita (STF, RTJ 68/64 e 168/199), estando seus depoimentos em consonância com o conjunto probatório.

"PROVA - Declaração da vítima e depoimento de Policiais - Eficácia:

As declarações prestadas pela vítima e os depoimentos de Policiais, se não confrontados por nenhum elemento que indique sua invalidez são provas absolutamente legítimas para sustentar um decreto condenatório, uma vez que o ofendido, por desconhecer o acusado, não tem razão para levianamente incriminá-lo, se inocente; e os Milicianos apenas pela função que exercem não podem ter suas afirmações comprometidas, já que não possuem interesse na condenação" (Apelação n.º 1.301.549/7- 11.ª Câmara - j. 24.06.02, cf. Ementário do TACrimSP n.º 35, p. 24).

A quantidade e variedade de drogas apreendidas (fls. 12 tabletes de maconha e 5 tabletes de cocaína - com peso total aproximado de 14,5 kg, conforme laudo de fls. 28/30), embaladas em tijolos, bem como a confissão extrajudicial judicial e os depoimentos dos policiais demonstram o tráfico, pois não teria como adquirir essa grande quantidade senão fosse traficante.

Segundo a jurisprudência:

"Ainda que se trate de réu viciado no uso de tóxico, a apreensão de grande quantidade da erva em seu poder, revela o objetivo de sua comercialização" (RJTJSP 75/343). Nesse sentido: RT 538/380.

"Tráfico de maconha - Quantidade da erva apreendida, aliada a outras circunstâncias, que induz à certeza da destinação ao comércio" (RJTJSP 97/492). No mesmo sentido: RJTJSP 123/473.

Assim, impõe-se a condenação do acusado, posto que a materialidade está provada pelo laudo de constatação (fls. 28/30) e laudo definitivo (fls. 55/57).

Passo a individualizar a pena a ser aplicada ao acusado, que segundo consta dos autos é primário (F.A/PI fls. 78; F.A fls. 132/134). O processo em andamento não pode ser considerado como antecedente em face do princípio do estado de inocência (fls. 142).

Levando em conta as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, fixo a pena-base para o acusado em 5 anos de reclusão e 500 dias-multa, à razão mínima, por inexistirem elementos quanto a real situação econômica do acusado. Deixo de diminuir a pena pela confissão, porque já foi aplicada no mínimo legal (Súmula 231 do STJ).

O M.P entendeu que deve ser aplicado o tráfico privilegiado, apesar da grande quantidade de drogas, diante da primariedade e por possuir ocupação lícita.

Observo que nos casos em que o autor do crime é considerado "mula" do tráfico, que foi contratado para transporte único, a jurisprudência do STJ e do STF é no sentido que apenas a grande quantidade de drogas, não conduz à conclusão de que integre ou se dedique a atividades criminosas, sendo possível a aplicação do benefício.

Nesse sentido: AgRg no HC 632857, Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, 5.ª Turma do STJ, j. em 13.09.2022, publicado DJE de 16.09.2022.

O entendimento da Primeira Turma do STF no julgamento do AgRg no RHC n. 138.117/MS, MINISTRA ROSA WEBER, DJe de 6/4/2021, também é nesse sentido:

"AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.

TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. ARTIGO 33, § 4º, DA LEI 11.343/2006. QUANTIDADE DE DROGA. INCIDÊNCIA DA MINORANTE. PATAMAR DE REDUÇÃO NA FRAÇÃO MÍNIMA. 1. A quantidade de droga apreendida não é, por si só, fundamento idôneo para afastamento da minorante do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006. Precedentes. 2. As circunstâncias concretas colhidas e sopesadas pelo magistrado sentenciante, autoridade judicial mais próxima dos fatos e das provas, apontam para a primariedade e para os bons antecedentes da agravada, e não indicam dedicação a atividade criminosa ou integração à organização criminosa. 3. Modulação

do redutor na fração mínima de 1/6, considerada a quantidade de droga apreendida. Proporcionalidade e adequação. Precedentes. 4. Agravo regimental conhecido e não provido".

O mesmo entendimento é da 2.º Turma do STF no RHC 159494 AgR, Ministro Edson Fachin:

"AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ORDEM CONCEDIDA PARA RECONHECER A INCIDÊNCIA DO REDUTOR DO § 4.º DO ART. 33 DA LEI 11.343/2006. SENTENÇA CONDENATÓRIA E ACÓRDÃO DA APELAÇÃO. AFASTAMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. TRANSPORTE DA DROGA NA CONDIÇÃO DE "MULA". AGENTE INTEGRAVA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. AUSÊNCIA DE FATOS CONCRETOS. MANUTENÇÃO DO DECISUM. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO".

Observo que no RHC 155299 AgR / MS (Relatora: Min. ROSA WEBER, Julgamento: 08/09/2020, Publicação: 10/12/2020, Primeira Turma do STF), foi mantido o tráfico privilegiado para o caso de 20 quilos de drogas, caso similar ao deste feito: "AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO. "MULA". INCIDÊNCIA DA MINORANTE. QUANTIDADE DE DROGA. CONSIDERAÇÃO EM DUAS FASES DA DOSIMETRIA. "BIS IN IDEM". 1. A condição de "mula" do tráfico não autoriza o afastamento da causa de diminuição do § 4.º do art. 33 da Lei de Tóxicos, sob o fundamento de dedicação do agente a atividades criminosas ou de sua integração a organização criminosa. Precedentes. 2. A quantidade da droga não pode influenciar, simultaneamente, o aumento da pena-base e a escolha da fração de redução a ser imposta na terceira etapa da dosimetria (§ 4.º do art. 33 da Lei 11.343/2006). Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido". No caso em tela, o réu foi contratado para atuar como "mula" do tráfico, transportando razoável quantidade de drogas (fls. 12 tabletes de maconha e 5 tabletes de cocaína - com peso total aproximado de 14,5 kg, conforme laudo de fls. 28/30). Há que se observar que não ficou demonstrada a habitualidade na medida em que, o réu tem 22 anos, é natural do Estado do Piauí e estava em São Paulo há poucos meses, confessou na fase policial e em juízo, aduzindo que aceitou transportar as drogas em razão de dificuldades financeiras, mas que exercia atividade remunerada (atendente na rede de lanchonetes Ragazzo). Logo, o réu preenche os requisitos para o tráfico privilegiado, posto que é primário, não ostenta antecedentes criminais, possui ocupação lícita, demonstrando que foi um ato isolado em sua vida e que não integra organização criminosa ou se dedica a atividades criminosas e inclusive confessou em juízo demonstrando arrependimento.

Diminuo a pena de 1/3, considerando a quantidade de drogas apreendidas (fls. 12 tabletes de maconha e 5 tabletes de cocaína - com peso total aproximado de 14,5 kg, conforme laudo de fls. 28/30), já que pequena quantidade nesta Comarca é inferior a 100 invólucros e enorme de toneladas, posto que é primário, não ostenta antecedentes criminais e não ficou demonstrado que se dedique a atividades criminosas ou integre organização criminosa (art. 33, § 4.º).

Estabelecendo a lei a redução entre um sexto a dois terços o réu não tem direito à redução no máximo legal. Ademais, a quantidade de droga não foi considerada na pena-base, pelo que pode ser levada em conta para aplicar o redutor. Observo que o art. 42 da Lei n.º 11.343/06 se reporta ao art. 59 do Código Penal, o qual diz respeito à fixação da pena, ou seja, individualização da pena, o que abrange toda a pena e não apenas a pena-base, pelo que obviamente pode a quantidade de droga ser considerada no redutor. Inclusive inúmeros Acórdãos confirmaram sentenças deste juízo no mesmo sentido, pelo que pode se dizer que há jurisprudência.

O regime inicial de cumprimento da pena será o aberto (art. 33, § 2.º, "c" e § 3.º, do Código Penal e HC 111.840/ES do STF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 14.06.2012 e HC 596.603 do STJ, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. em 08.09.2020), porque o réu é primário e não ostenta antecedentes criminais, pelo que as circunstâncias judiciais são favoráveis e foi afastado pela jurisprudência do STF e do STJ o caráter hediondo do tráfico privilegiado.

Ante o exposto, julgo PROCEDENTE a ação e, em consequência, CONDENO JOÃO VICTOR BORGES DE OLIVEIRA à pena de 3 (TRÊS) ANOS e 4 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO, INICIALMENTE NO REGIME ABERTO e 333 (TREZENTOS E TRINTA E TRÊS) DIAS-MULTA, à razão

mínima, por se achar incurso no art. 33, "caput", da Lei n.º 11.343/06. Considerando a redação do art. 44, § 2.º, do Código Penal, bem como o decido no HC 596.603 do STJ, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. em 08.09.2020, sendo a pena privativa de liberdade superior a um ano a substituo por duas restritivas de direitos: prestação de serviços à comunidade e interdição temporária de direitos consistente em proibição de frequentar determinados lugares, a serem fixados pelo juízo da execução, que são as mais adequadas para reprimir a sua conduta. A substituição por multa não foi aplicada, porque insuficiente para punir o crime e também diante da situação econômica do réu. A pena restritiva de direitos terá a mesma duração da pena privativa de liberdade substituída (art. 55 do Código Penal). O acusado poderá recorrer em liberdade, uma vez que é primário e após a substituição legal foram cominadas apenas penas de multa e restritiva de direitos. Expeça-se alvará de soltura clausulado. Sem custas (Lei n.º 11.608/03), por ser beneficiário da Assistência Judiciária (art. 5.º, inc. LXXIV, da Constituição Federal; STF- RE 313348 AgR/RS, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, j. 15.04.03). Quanto à mala de viagem marca Olympus Automotive, apreendida (fls. 25) e já periciada (fls. 80), tendo em vista que não tem possui econômico, oficie-se desde já informando que não interessa mais aos autos podendo ser eliminada. Em relação ao telefone celular marca Motorola modelo XT2015-2, apreendido (fls. 25), já periciado (fls. 80), não há provas nos autos de que era utilizado ou fosse proveito do tráfico, pelo que oficie-se, desde logo, informando que não interessa mais ao feito e que decorrido o prazo do art. 122 do CPP pode ser dado o destino pertinente. A liberação depende de demonstração da propriedade. Transitada em julgado, lance-se o nome do acusado no Rol dos Culpados, oficie-se para incineração da droga mantida para contraprova (fls. 46) e providencie-se o cálculo da multa, abrindo-se vista às partes. Publicada em audiência, saem os presentes intimados. Façam-se as anotações e comunicações de praxe. Diadema, 13 de outubro de 2022.

MARIA DA CONCEIÇÃO PINTO VENDEIRO

Juíza de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA